

1500634-18.2018.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido:

AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500634-18.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500634-18.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVAN GOMES DE SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual EDVAN GOMES DE SANTANA, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Narra a Denúncia (fls. 43/45) que, no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 11h55min, na Rua Basílio Fernandes Barros, n.º 10, Aliança, nesta cidade e comarca de Osasco, EDVAN GOMES DE SANTANA, qualificado às fls. 08/09, com fotografia à fl. 16, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 10 (dez) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 28,12 gramas, e 16 (dezesesseis) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 8,76 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 07, laudo de constatação às fls. 23/25, fotografias às fls. 18/22 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Narra ainda a denúncia que, segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, momento em que avistaram o denunciado, o qual trazia uma sacola nas mãos e, ao notar a presença policial, apresentou atitude

suspeita, passando por trás de um veículo que estava estacionado na via pública.

Diante disso, os milicianos decidiram abordá-lo e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, no local onde o denunciado fora visto passando por um veículo, localizaram uma sacola plástica que ele havia dispensado, a qual continha 10 (dez) porções de maconha e 16 (dezesesseis) invólucros contendo cocaína, todos individualmente embalados e prontos para comercialização (vide fotografias às fls. 18/22).

Indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu que trazia consigo a sacola plástica apreendida. Pela grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como circunstâncias de sua apreensão, é certo que se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01.

Auto de exibição e apreensão às fls. 07.

Fotografia dos entorpecentes apreendidos às fls. 18/22.

Laudo Pericial Toxicológico às fls. 23/25. Laudo toxicológico definitivo às fls. 48/50.

Em sede de audiência de custódia (fls. 28/29 e 31), foi relaxada a prisão em flagrante do acusado. Alvará de soltura cumprido às fls. 32.

A denúncia foi oferecida às fls. 43/35.

Às fls. 60, foi determinada a notificação do acusado.

O acusado foi notificado (fls. 71/76). Em defesa prévia apresentada às fls. 81 por intermédio da Defensoria Pública, foi apresentada negativa geral.

Às fls. 87/89, este juízo recebeu a denúncia, mesma oportunidade em que designou audiência de instrução, debates e julgamento presencial para o dia 02.08.2022, às 11h30.

Folha de antecedentes às fls. 107/108.

Ocorre que a audiência ora designada restou prejudicada em razão da ausência do acusado (fls. 109), uma vez que não foi realizada tentativa de intimação no endereço em que foi citado às fls. 76. Assim, foi redesignada audiência para o dia 20.09.2022, às 10:00 horas.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. Foi decretada a revelia do réu.

Em debates, a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa pediu a absolvição por ausência de provas. Alegou que não havia motivo para a abordagem do réu. Sustou que não há provas de que o entorpecente seria entregue a terceiros. Alegou que não estava na posse de dinheiro. Não há indícios de que ele estaria praticando tráfico de drogas. Em caso de condenação, pede a desclassificação para o art. 28 pois não está claro a destinação da droga. Requereu o privilégio, a pena no mínimo, além da substituição por restritivas.

É relatório.

Fundamento e decido

i - Do mérito

A - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 48/50) e fotografias (fls. 18/22).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que o réu, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que pequena, trazia entorpecentes destinado a terceiras pessoas.

O réu não foi ouvido em juízo posto que revel. Desta sanção processual não é possível a extração de qualquer consequência jurídica.

Por outro lado, em que pese a ausência de versão do réu, as provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (laudo e fotografias), permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável.

Com efeito, os policiais militares, na fase oral, em resumo, relataram que faziam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e viram o réu caminhando em direção à viatura com uma sacola nas mãos. Neste momento, ao ver a viatura, o réu foi para trás de um veículo. Perceberam que o réu, ao sair de trás deste veículo, não mais estava com a sacola nas mãos. O réu foi abordado e com ele nada encontrado. Entretanto, atrás do veículo, não chão, localizaram a sacola com o entorpecente descrito na inicial, maconha e cocaína.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais.

Com efeito, os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que avistaram o réu com uma sacola nas mãos e que este, ao avistar a viatura, dirigiu-se para atrás de um carro e ao sair já estava sem sacola. Foi diligenciado o local e localizaram a sacola com as drogas descritas na inicial.

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, que no dia 19 de outubro de 2018, por volta das 11h55min, na Rua Basílio Fernandes Barros, n.º 10, Aliança, nesta cidade e comarca de Osasco, EDVAN GOMES DE SANTANA, qualificado às fls. 08/09, com fotografia à fl. 16, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 10 (dez) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 28,12 gramas, e 16 (dezesseis) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 8,76 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas, a quantidade e as condições nas quais se desenvolveu a ação (o réu escondeu a sacola atrás do carro, fato não negado pela defesa). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com o réu e se destinava ao comércio espúrio, em que pese não ter sido localizado com o réu dinheiro ou anotações como alega a defesa. Logo, não há falar no art. 28 da Lei de Drogas.

B – Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (sem condenação não apta a gerar reincidência) – fls. 26. Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o réu se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: AGRADO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRADO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer à organização criminosa.

Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela. Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há qualquer mínimo elemento que demonstre de forma pressuposta envolvimento com organização criminosa.

ii - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a quantidade de drogas é não significativa e, ainda, o réu é primário e não ostenta antecedentes.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

iii- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:
CONDENO EDVAN GOMES DE SANTANA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 177 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração aos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

iv - Demais deliberações

Pela natureza da sanção o réu poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

P.R.I.C.

Osasco, 20 de setembro de 2022.